

## 2013년도 제50회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

| 교시  | 시험과목   | 시험시간 | 수험번호 | 성명 |
|-----|--------|------|------|----|
| 2교시 | 디자인보호법 | 120분 |      |    |

### 【 A-1 】 (30점)

응접탁자 1개, 소파 3개, 쿠션 1개로 구성된 “한 벌의 응접세트” 디자인A를 2012. 4. 7. 출원한 甲은 자신이 출원한 디자인A의 구성물품 중 1구성물품인 ‘쿠션’ 디자인과 유사한 디자인B를 동업자 乙이 2012. 4. 12. 출원하고 판매하고 있음을 알게 되었다. 이 경우 디자인 A의 등록가능성에 대하여 구체적으로 설명하고, 디자인B의 등록 및 실시를 저지하기 위하여 甲이 취할 수 있는 적절한 조치사항을 논하시오. (단, 시행규칙에서는 “한 벌의 응접세트” 디자인의 구성물품은 “응접탁자, 소파”로 정하고 있어, ‘쿠션’을 포함한 디자인A의 한 벌의 응접세트 디자인 등록요건 충족여부는 명확하지 않다.)

### 【 A-2 】 (20점)

각종 완구류의 제조·판매업자인 甲은 각각의 구성물을 모두 조립하면 1형태의 코끼리가 완성될 수 있는 7개의 구성물과 사용자의 조립방법에 따라 다양한 형태의 코끼리가 완성될 수 있는 15개의 구성물을 각각 창작하였다. 상기 각 구성물들의 디자인 성립요건과 1디자인 1출원주의 요건을 검토하고, 이들 각 구성물들이 디자인등록을 받을 수 있는 방법과 이들 디자인권의 효력의 차이에 대하여 설명하시오.

【 B-1 】 (30점)

디자인권자 甲회사는 乙이 고의로 甲회사의 디자인을 모방한 유사물품을 제조·판매하자 이로 인하여 손해를 보았다며 乙을 침해죄로 고소하는 한편 乙을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다. 그 후 甲회사는 변리사 丙에게 상담하면서 甲회사의 분비서면에는 영업비밀에 해당하는 디자인형상의 제조과정상 노하우가 기술되어 있다며 乙이 이를 乙 자신의 사업에 이용할 경우 비밀누설죄로 고소할 계획이라고 밝혔다. 이 경우 영업비밀을 유지하기 위해서 甲회사가 취할 수 있는 조치사항에 대하여 변리사 丙의 입장에서 설명하시오.

【 B-2】 (20점)

변리사 甲은 지방에 소재하는 어떤 사찰로부터 그 절 마당에 있는 석탑A와 유사한 ‘석탑모양의 납골보관함’에 관한 디자인B의 국내디자인등록이 가능한지 대하여 문의 받았다. 甲이 디자인B의 등록가능성에 대하여 검토할 사항을 설명하시오.

## [A-1]문 (30점)

### 【A-1】 (30점)

응접탁자 1개, 소파 3개, 쿠션 1개로 구성된 “한 벌의 응접세트” 디자인A를 2012. 4. 7. 출원한 甲은 자신이 출원한 디자인A의 구성물품 중 1구성물품인 ‘쿠션’ 디자인과 유사한 디자인B를 동업자 乙이 2012. 4. 12. 출원하고 판매하고 있음을 알게 되었다. 이 경우 디자인 A의 등록가능성에 대하여 구체적으로 설명하고, 디자인B의 등록 및 실시를 저지하기 위하여 甲이 취할 수 있는 적절한 조치사항을 논하시오. (단, 시행규칙에서는 “한 벌의 응접세트” 디자인의 구성물품은 “응접탁자, 소파”로 정하고 있어, ‘쿠션’을 포함한 디자인A의 한 벌의 응접세트 디자인 등록요건 충족여부는 명확하지 않다.)

### 【출제문제 평가】

본 문제는 한 벌의 물품디자인(A)에 대한 성립요건 만족 여부에 따라 타인이 해당 한 벌의 물품디자인의 일부 구성물품과 유사한 디자인(B)을 출원 및 실시하고 있는 경우, 문제되는 등록요건과 관련한 등록 저지를 위한 조치 및 침해 성립을 전제로 한 실시 저지를 위한 조치가 주논점인 문제입니다. 한 벌의 물품디자인의 경우 올해 충분히 출제가 예상되었던 문제이기 는 하나, 등록가능성 및 침해문제와 결부하여 다 논점으로 출제되었을 뿐만 아니라 성립요건 만족여부가 불명확하여 이를 나누어서 답안을 기재하여야 하는지 등이 불명확하여 실제로 수험생들이 느꼈을 체감 난이도는 보다 높았을 것으로 판단됩니다. 이하 본 문제에 대한 답안에 대하여 설명드리겠습니다.

## I. 문제의 제기 (2점)

디자인보호법은 심사 편의를 위하여 1물품에 대한 1형태 즉, 1디자인을 1출원하여야 하는 1디자인 1출원주의를 원칙으로하되, 다물품이라도 일정한 요건에 따라 이를 1디자인으로 의제하여 출원인의 편의를 도모하는 제도를 인정하고 있다. 사안은 이 중 한 벌의 물품디자인과 관련된 것으로, 甲의 한 벌의 물품디자인 A에 대한 출원(이하, X출원이라 함)의 타인인 乙의 일부 구성물품에 대한 디자인 B 출원(이하, Y출원이라 함)과의 관계를 고려하여 등록가능성을 검토한 후, 최선 창작자인 甲이 乙에 대해 취할 수 있는 등록 및 실시 저지를 위한 적절한 조치를 검토한다.

## II. 甲의 X출원에 대한 등록가능성 (8점)

### 1. 한 벌의 물품디자인 제도의 의의·취지 및 연혁

### 2. 성립요건

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은 원칙적으로 시행규칙 별표 5에서 정하는 한 벌 물품이어야 하고, 심사기준 별표 1에서 적어도 2 이상이어야 하나, 이외 물품이 포함되더라도 한 벌의 물품으로 정해진 물품과 동시에 사용되는 것이 상거래 관행상 당업계에서 인정될 수 있는 경우에는 정당한 한 벌 물품으로 인정한다는 내용은 반드시 기재하여 주셔야 합니다.

### 3. 한 벌의 물품 디자인 A의 등록요건 판단 (간략히!!)

### 4. 소결

(1) 사안에서 甲의 X출원은 시행규칙에서 정한 응접탁자 1개 및 소파 3개의 2이상의 물품을 포함하고 있고, 쿠션의 경우 원칙적으로 시행규칙에서 정한 “한 벌의 응접 세트”에는 포함되어 있지 않으나, 일반적으로 소파 사용시 관념적 및 실제 가구업계 거래 관행상 동시에 사용됨이 인정될 수 있으므로, 한 벌 전체로서의 통일성이 인정되고, 다른 거절이유가 문제되지 않음을 전제로 등록 가능할 것이다.

(2) 다만, 사안에서는 명확하지 않으나, 응접탁자, 소파 및 쿠션을 포함한 한 벌의 물품디자인 전체로서 통일성이 인정되지 않거나 다른 등록요건이 문제되는 경우에는, 2이상의 디자인으로 취급되어 1디자인 1출원주의 위반에 해당할 수 있고, 이 경우에는 후술하는 분할출원, 삭제보정 또는 취하 후 재출원 등의 별도의 조치를 취해야

등록이 가능할 것이다.

### Ⅲ. 甲의 Y출원 등록저지를 위한 조치 (10점)

#### 1. 전제

甲의 “한 벌의 응접세트”에 대한 X 출원의 디자인 등록요건 충족 여부가 명확하지는 않으나, 사안에서 쿠션에 대한 최선 창작자는 甲이므로 보호 받는 것이 정당하다. 따라서, 甲의 X출원에 대한 “한 벌의 응접세트” 디자인의 등록요건이 충족됨을 전제로 하여 Y출원에 대한 문제되는 거절이유를 살핀 후, 최선 창작자인 甲이 이에 대한 등록을 저지할 수 있는 조치를 검토한다.

#### 2. Y출원에 대한 문제되는 거절이유 (확대된 선출원주의-제5조 제3항)

(1) 의의·취지 및 연혁

(2) 요건

단, 요건 부분에서 ‘한 벌의 물품’ 및 ‘구성물품’의 포함관계에 따른 확대된 선출원주의 적용여부에 대하여 기재해 주시는 것이 중요합니다.

(3) 흥결시 효과

(4) 소결

Y출원은 2012년 4월 12일에 乙에 의해 출원된 ‘쿠션’에 대한 B디자인에 관한 것으로, 이미 타인인 甲이 그와 유사한 디자인의 ‘쿠션’을 포함한 “한 벌의 응접세트”에 대한 디자인A의 X출원이 2012년 4월 7일에 출원되었는바, 甲의 X출원이 출원공개 등록공고되어 디자인공보에 게재되는 경우 Y출원은 확대된 선출원주의 위반의 거절이유가 있다.

#### 3. 甲의 조치 (정보제공제도-제23조의5)

(1) 의의 및 취지

(2) 요건 및 절차

(3) 효과

#### 4. 소결

(1) 甲은 출원 중인 乙의 Y출원에 대한 등록을 저지하기 위하여 상기 검토대로 Y출원이 확대된 선출원주의 위반에 해당하므로 등록될 수 없다는 취지의 정보를 자신의

X출원에 대한 서류를 증거로 제시하여 특허청장에게 제공하는 조치를 취할 수 있다.  
(2) 추가적으로, 甲은 자신의 X출원에 대한 출원공개 신청의 조치를 통한 출원공개 게재에 의하여 미연에 Y출원이 확대된 선출원주의에 적용되도록 할 수 있으며, 또는 乙의 판매 등을 입증하여 우선심사를 신청하는 조치 등으로 조기 권리화를 통한 등록공개 게재에 의하여 조기에 Y출원이 확대된 선출원주의에 적용되도록 할 수 있다.

#### IV. 乙의 디자인B 실시저지 조치 (8점)

##### 1. 침해의 의의 및 디자인권 침해의 특수성

침해의 의의 간단하게 쓰시고 디자인권 침해의 특수성을 고려하여 ‘간접침해’ 제도를 인정하고 있다는 내용의 언급이 필요합니다.

##### 2. 乙의 B디자인 실시가 甲의 한 벌의 물품 디자인권의 침해인지 여부

###### (1) 전제

乙은 정당권원 없이 甲의 유효한 한 벌의 디자인권에 대하여 판매 등의 업으로서 실시하고 있으므로 보호범위 내의 실시인지가 문제된다는 점을 기재하셔야 합니다.

###### (2) 한 벌의 물품의 디자인권의 효력 (직접침해여부)

특히, 한 벌의 물품 디자인권의 효력을 제도 인정 취지에 비추어 전체로서 하나의 디자인권만이 발생하며 일부 구성물품 각각에 대한 디자인권이 발생하는 것은 아니므로 보호범위 내의 실시가 아니라는 점을 강조하셔야 합니다.

###### (3) 간접침해 여부

한 벌 물품의 구성물품은 그 자체가 독립거래의 대상이 될 수 있을 뿐만 아니라 고유의 용도가 있어 간접침해에서 말하는 ‘타용도’가 없는 전용품이라고 볼 수 없으므로(또는 ‘쿠션’을 구체적으로 언급하시면서 ‘쿠션은 자체로 소파뿐만 아니라 침대 등에도 사용될 수 있는 등 오로지 소파와의 사용만이 전제되지 않으므로’ 라는 기재를 통하여 전용품이 아니라고 사안을 포섭하실 수 있습니다.) 간접침해의 성립될 수 없다.

##### 3. 소결

따라서, 甲은 단순히 “한 벌의 응접세트”에 대한 출원만으로는 乙의 판매 등의 실시를 저지할 수 없다.

## V. 사안의 해결 (2점)

(1) 甲의 X출원은 등록 가능하고, 乙의 Y출원에 대한 확대된 선출원주의 위반에 대한 정보를 제공하여 등록을 저지할 수 있으나, 이하 보론에 해당하는 추가적인 조치 없이 단순히 “한 벌의 응접세트”에 대한 디자인권으로는 乙의 ‘쿠션’ 물품에 대한 실시 행위를 저지할 수 없다.

(2) (보론) 甲은 “한 벌의 응접세트”에 대한 출원이 성립요건을 만족하지 않음을 전제로 한 제11조 제1항 위반에 따른 거절이유가 있는 경우 분할출원이 가능하고, 이 경우 ‘쿠션’에 대한 분할출원으로 상기 확대된 선출원주의 이외에 선출원주의(제16조 제1항) 위반 등을 이유로 한 정보제공을 할 수 있으며, 보상금청구권 발생을 위한 조치로서 출원공개 신청, 경고의 조치를 병행할 수 있고, 우선심사를 통한 조기 등록을 도모하여 등록 후 보상금청구권 및 쿠션에 대한 디자인권 행사 등의 조치를 강구할 수 있다.

**[A-2]문 (20점)**

**【A-2】 (20점)**

각종 완구류의 제조·판매업자인 甲은 각각의 구성물을 모두 조립하면 1형태의 코끼리가 완성될 수 있는 7개의 구성물과 사용자의 조립방법에 따라 다양한 형태의 코끼리가 완성될 수 있는 15개의 구성물을 각각 창작하였다. 상기 각 구성물들의 디자인 성립요건과 1디자인 1출원주의 요건을 검토하고, 이들 각 구성물들이 디자인등록을 받을 수 있는 방법과 이들 디자인권의 효력의 차이에 대하여 설명하시오.

**【출제문제 평가】**

본 문제는 디자인보호법상 합성물과 집합물에 대한 취급의 차이점에 근거하여 문제되는 등록요건(디자인 성립요건 및 1디자인 1출원주의) 검토 및 디자인 등록을 받을 수 있는 방법과 등록된 경우 디자인권의 효력의 차이점을 주논점으로 한 문제입니다. 특히, 각 구성물을 조립하는 경우 1형태 및 다양한 형태로 완성될 수 있다는 근거만 제시되어 먼저, 이에 대한 명확한 개념을 언급하여 주어야 합니다. 즉, 문제의 제기에 완성형태가 단일한 조립완구의 경우 합성물의 구성각편으로 취급되며 완성형태가 다양한 조립완구의 경우 집합물로 취급됨을 언급하는 것이 필요하다고 판단됩니다.



## I. 문제의 제기 (2점)

- (1) 합성물이란, 2이상의 구성물이 서로 결합하여 하나의 물품을 이루는 것으로 그 구성물이 개성을 갖지 않는 것을 말한다. 또한 집합물이란, 2이상의 단일물 또는 합성물이 집합하여 그 집합물 자체로서도 경제적 가치를 갖는 동시에 그것을 구성하는 개개의 물품도 경제적 가치를 갖는 것을 말한다.
- (2) 상기 점을 근거로, 사안에서 완성형태가 단일 또는 다양한 조립완구의 디자인보호법상 성립요건(물품성) 및 1디자인 1출원주의 만족여부를 검토하고, 각각의 조립완구의 디자인보호법상 등록받기 위한 방법 및 등록 후 디자인권의 효력의 차이점을 설명한다.

## II. 각 구성물들의 디자인 성립요건 및 1디자인 1출원주의 검토 (7점)

### 1. 성립요건

- (1) 디자인보호법 제2조 제1호 디자인의 정의 규정
- (2) 물품성

특히, 이 부분에서는 물품성 요건 중에서도 ‘독립성’에 대하여 구체적인 예시 등을 들어 풍부하게 언급하여 주시는 것이 중요합니다.

- (3) 각 구성물에 대한 성립요건 검토
  - ① 조립하면 1형태의 코끼리가 완성될 수 있는 7개의 구성물
  - ② 조립하면 다양한 형태의 코끼리가 완성될 수 있는 15개의 구성물

### 2. 1디자인 1출원주의

- (1) 의의 및 취지

특히, 1디자인 1출원주의 원칙 및 이를 원칙으로 하는 구체적인 이유(출원디자인 심사 및 등록 후 권리파악의 명확화)를 반드시 언급해주셔야 합니다.

- (2) 제11조 제1항

특히, 요건 중 ‘1물품’에 대한 내용을 풍부하게 작성하여 주시는 것이 중요합니다.

- (3) 제11조 제2항 (간략히!!)
- (4) 각 구성물에 대한 1디자인 1출원주의 검토
  - ① 조립하면 1형태의 코끼리가 완성될 수 있는 7개의 구성물
  - ② 조립하면 다양한 형태의 코끼리가 완성될 수 있는 15개의 구성물

### III. 각 구성물들의 디자인 등록을 받을 수 있는 방법 (5점)

#### 1. 전제

상기 검토대로, 완성형태가 단일한 7개 구성물의 경우 전체로서 독립하여 거래대상이 되며 1물품으로 인정되므로 구성물은 부분디자인으로 출원되어야 하며, 완성형태가 다양한 15개 구성물의 경우 각각의 구성물이 독립하여 거래대상이 되며 1물품이므로 구성물은 각각 전체디자인으로 디자인등록 출원하여야 등록 가능한바 이를 전제로 검토한다.

#### 2. 7개의 구성물의 부분디자인으로 등록받기 위한 방법

(1) 부분디자인 의의·취지

(2) 요건 및 절차

특히, 취지 기재 등의 출원서 기재사항 및 도면에 대한 내용을 중점적으로 기재하여야 합니다.

#### 3. 15개의 구성물의 전체디자인으로 등록받기 위한 방법

(1) 일반적인 디자인등록출원서 기재사항 및 도면에 대한 요건

(2) 일반적인 절차

### IV. 각 구성물들의 디자인권 효력상의 차이 (4점)

#### 1. 7개의 구성물의 부분디자인권의 효력

#### 2. 15개의 구성물의 전체디자인권의 효력

특히, 두 가지 경우 모두 제41조에 의한 디자인권 행사가 가능하고, 원칙적으로 부분디자인권의 효력이 전체디자인권 보다 유리하다는 내용, 다만 사안에서는 15개 구성물의 경우 각각의 1디자인권 행사가 가능하므로 오히려 더 넓은 보호범위를 인정받을 수 있다는 점을 기재하셔야 합니다. 추가적으로 구성물 자체를 실시할 경우 디자인권의 침해가 성립될 수 있는지에 대한 차이점을 간략하게 언급하시면 좋을 것입니다.

#### 3. 보론

보론으로 양자 모두 전체로서 디자인 등록받은 경우를 상정한 후 간접침해 성

립과 관련하여서도 차이점이 인정될 수 있을 것으로 판단됩니다(사건). 즉, 7개의 구성물은 단일 완성 형태를 가지므로 타용도는 인정될 수 없는 반면, 다양한 완성 형태를 가지는 15개의 구성물은 타용도가 인정될 수 있으므로 간접침해 여부가 달라질 것으로 판단됩니다. 이러한 내용을 살짝 언급해주시면 좋을 것입니다.

## V. 사안의 해결 (2점)

- (1) 합성물과 집합물 각각의 구성물에 대한 디자인보호법상 취급에 따라 출원 절차 및 등록 후 차이점이 인정된다.
- (2) 따라서, 구성물에 대한 창작적 가치가 인정되는 경우, 이에 대한 보호를 위하여 가능한 경우 부분디자인 및 전체디자인으로 모두 등록받아 둌으로써 제3자의 일부 모방 등에 의한 실시로 인한 추후 침해문제에 대한 사전 대비를 하는 것이 바람직할 것이다.

**[B-1]문 (30점)**

**【B-1】 (30점)**

디자인권자 甲회사는 乙이 고의로 甲회사의 디자인을 모방한 유사물품을 제조·판매하자 이로 인하여 손해를 보았다며 乙을 침해죄로 고소하는 한편 乙을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다. 그 후 甲회사는 변리사 丙에게 상담하면서 甲회사의 분비서면에는 영업비밀에 해당하는 디자인형상의 제조과정상 노하우가 기술되어 있다며 乙이 이를 乙 자신의 사업에 이용할 경우 비밀누설죄로 고소할 계획이라고 밝혔다. 이 경우 영업비밀을 유지하기 위해서 甲회사가 취할 수 있는 조치사항에 대하여 변리사 丙의 입장에서 설명하시오.

**【출제문제 평가】**

본 문제는 2012년 한·미 FTA 체결에 의한 발효 시점에 따른 개정법에서 도입된 비밀유지명령제도에 대한 준단문형 문제입니다. 이는 작년 개정에 맞추어 출제가 예상되었으나 출제되지 않고 올해 출제되어 수험생들을 물론 저도 문제를 보자마자 많이 당황하게 되었습니다. 더욱이, 이를 위한 법조문 이외에 수험적으로 공부할 만한 문헌이 없었을 것이라 생각되어 실제로 시험을 보신 여러분들은 더욱 놀라셨을 것입니다. 그러나, 기본적인 단문 목차에 맞추어 답안지를 법조문을 위주로 잘 정리하여 기재하신 경우라면 충분히 배점을 받으실 수 있으실 것으로 판단됩니다. 가장 큰 논점이 ‘비밀유지명령제도’이므로 이에 대한 기재를 중점적으로 법조문을 토대로 기재하시되, ‘변리사 丙의 입장에서 설명하시오’라는 말미에 따라 현재 甲회사가 乙에 대하여 침해죄 이외에도 비밀누설죄로 고소하려고 하고 있음에 비추어 그에 대한 조언도 기재하여 주시는 것이 가장 바람직하다고 판단됩니다.

## I. 문제의 제기 (2점)

사안에서 甲회사의 영업비밀 유지를 위하여 현재 침해로 인한 손해배상청구소송이 진행 중인바 2012년 도입된 비밀유지명령제도에 대하여 구체적으로 검토한다. 또한, 변리사로서 추가적으로 침해죄 및 비밀누설죄에 대한 인정 여부 등과 관련하여 甲회사에게 조언할 사항들에 대하여 검토한다.

## II. 甲회사가 취할 수 있는 조치 (비밀유지명령제도-제81조의2) (22점)

### 1. 의의 및 도입취지

(1) 비밀유지명령제도는 법원으로 하여금 디자인권 등의 침해에 관한 소송에서 당사자가 제출한 준비서면 등에 영업비밀이 포함되어 있고 그 영업비밀이 공개 되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있는 경우 등에는 당사자의 신청에 따라 결정으로 해당 영업비밀을 알게 된 자에게 소송 수행 외의 목적으로 영업비밀을 사용하는 행위 등을 하지 아니할 것을 명할 수 있는 제도를 말한다.

(2) 이는 한·미 FTA 현정물을 국내법에 반영한 것으로서, 소송절차에서 알려지게 된 영업비밀을 보호하여 기업의 경영활동 위축을 막을 수 있도록 하고, 현실적으로 서류제출을 거부하는 사례가 급증함에 따른 문제점을 해소함과 동시에 소송에서의 손해 입증이 용이해지고, 심리의 충실을 도모하여 소송촉진을 이룰 수 있게 하기 위한 취지이다.

### 2. 요건

(1) 제81조의2 제1항 기재

(2) ‘영업비밀’에 대한 특유 요건

특히, 이 부분에서는 “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률”에서 규정하는 영업비밀로서 성립되어야 함을 기재하신 후, 부경법 제2조 제2호의 법조문을 참고하셔서 기재하시면 좋을 것입니다. 보다 구체적으로, “본 요건에서 영업비밀이라 함은 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.”라고 기재하시면 될 것입니다.

### 3. 절차

제81조의2 제2항 및 제3항 기재

#### 4. 효력 및 불복

제81조의2 제4항 및 제5항 기재

#### 5. 비밀유지명령의 취소 (제81조의3)

- (1) 요건
- (2) 절차
- (3) 효력 및 불복

#### 6. 소송기록 열람 등의 청구 통지 (제81조의4)

- (1) 열람 등의 청구 통지 (제81조의4 제1항)
- (2) 열람 금지 기간 (제81조의4 제2항)
- (3) 열람 금지의 예외 (제81조의4 제3항)

문제에서 甲회사의 대리인이 될 수 있는 자로서 변리사 丙의 입장에서 비밀을 유지하기 위하여 검토하는 것이므로 “비밀유지명령의 취소(제81조의3)” 또는 “소송기록 열람 등의 청구 통지(제81조의4)”에 대한 내용은 비밀유지명령(제81조의2) 보다는 조금 적게 할애하시는 것이 바람직하다고 봅니다.

#### 7. 비밀유지명령 위반죄 (제85조의2)

- (1) 벌칙 (제85조의2 제1항)
- (2) 친고죄 규정 (제85조의2 제2항)

### III. 甲회사의 乙회사에 대한 추가적인 조치에 대한 조언 (4점)

#### 1. 침해죄 성립여부 및 그에 따른 조치

- (1) 침해의 의의 및 디자인권 침해의 특수성에 따른 관련 규정
- (2) 소결

변리사로서 현재 침해죄 성립하고 있으므로 다른 민사상의 조치도 취할 수 있음을 조언할 수 있다는 내용의 기재를 하실 수 있습니다.

#### 2. 비밀누설죄의 적용여부

- (1) 제86조

(2) 단, 사안에서 乙은 직무상 지득한 것으로 볼 수 없어 비밀누설죄 고소는 불가능함을 조언할 수 있다.

#### iv. 사안의 해결 (2점)

(1) 변리사 丙은 甲회사에게 소송상 비밀유지명령제도에 따른 조치를 통하여 영업비밀을 유지할 수 있다는 설명과 함께, 비밀누설죄는 적용될 수 없고 상기 명령제도에 따른 비밀유지명령위반죄를 물을 수 있으나, 친고죄인 점에 비추어 甲의 고소를 유도하여야 할 것이다. 또한, 침해로 인한 다른 민·형사상의 조치를 취할 수 있음도 조언할 수 있다.

(2) 상기 외에도 사안의 甲회사는 영업비밀보호에 대한 관련법으로서 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있고, 디자인형상의 제조과정은 기술적 가치가 인정되는 경우를 전제로 특허법으로 보호받을 수 있으며, 만일 형상 자체에 대한 영업 비밀을 유지할 필요가 있는 경우 디자인보호법상 특유적으로 비밀디자인제도도 활용할 수 있을 것이다.

**[B-2]문 (20점)**

**【B-2】 (20점)**

변리사 甲은 지방에 소재하는 어떤 사찰로부터 그 절 마당에 있는 석탑A와 유사한 ‘석탑모양의 납골보관함’에 관한 디자인B의 국내디자인등록이 가능한지 대하여 문의 받았다. 甲이 디자인B의 등록가능성에 대하여 검토할 사항을 설명하시오.

**【출제문제 평가】**

본 문제는 전형적인 창작성 논점의 등록가능성을 묻는 준사례형 문제입니다. 특히 본 문제를 단순히 창작성만의 논점으로 생각하시고 창작성 논점만을 기재하신 경우, 많은 점수를 배점받기 어려울 것입니다. 항상 말씀드리지만, 디자인보호법에서는 문제 말미에 주목하신 후, ‘가장’ 등의 단어가 없는 이상 다논점이라는 생각을 절대 버리시면 안될 것입니다. 따라서, 본 문제는 원칙으로 돌아가 출원디자인의 국내등록가능성을 묻는 문제이므로 공지를 전제로한 신규성 및 창작성은 물론, 그 판단의 전제조건인 성립요건 및 공업상 이용가능성을 먼저 검토하시는 것이 중요합니다. 다만, 석탑A는 건조물에 해당하고, 주지형태로 볼 수 있는지 및 용이창작 가능한지 여부가 가장 주된 논점이라고 할 수 있습니다.



## I. 문제의 제기 (2점)

사안의 甲의 ‘납골보관함’에 관한 디자인B 출원(이하, X출원이라 함)의 국내등록 가능성과 관련하여 이미 공지되어 있는 건조물인 석탑A와 유사한 모양을 하고 있으므로 창작성이 가장 문제된다. 다만, 이들 요건의 판단의 전제인 성립요건, 공업상 이용가능성 및 신규성을 먼저 판단한다. 또한, 추가적으로 X출원의 등록을 위한 절차 등의 요건 등도 함께 검토한다.

## II. 甲의 X출원의 등록가능성에 대한 검토사항 (16점)

### 1. 디자인보호법상 디자인으로 성립되는지 여부 (2점)

- (1) 성립요건
- (2) 소결

특히, 본 문제에서는 주로 물품성이 문제될 수 있으며, 물품인 납골보관함이 석탑 모양이라고만 제시되어 형상 수반 여부가 불명확하므로 간단히만 형태성을 따져주시면 좋을 것 같습니다.

### 2. 공업상 이용가능성 만족여부 (2점)

- (1) 의의·취지
- (2) 요건
- (3) 소결

물품인 ‘납골보관함’은 공업적 생산방법으로 양산 가능하므로 인정된다는 취지로 간략하게 검토하여 주시면 되겠습니다.

### 3. 신규성 만족여부 (3점)

- (1) 의의·취지
- (2) 요건
- (3) 소결

사안에서 X출원디자인 B는 ‘납골보관함’을 물품으로 한 것으로, 그 모양이 이미 공지된 건조물 석탑A와 유사하나 물품이 상이하여 형태의 유사여부 상관없이 비유사한 디자인에 해당하므로 신규성 위반에 해당하지 않는다.

### 4. 창작성 만족여부 (7점)

- (1) 의의·취지
- (2) 판단
- (3) 구체적인 흠결 유형
- (4) 흠결시 효과
- (5) 소결

① 특히, 석탑A는 건조물에 해당하는 것으로 국내 주지 형태로 볼 수 있어 용이창작 판단을 위한 인용디자인에 해당할 수 있으나, 석탑과 납골보관함은 물품의 용도·기능 및 일반적인 형태 등의 관련성에서 판단할 경우 이종물품에 해당하고 디자인의 전용이 당업계의 상식으로 이루어 질 수 없다고 판단되는바 창작성을 만족한다고 할 것이다. ② 또한, 석탑A에 대한 모양을 보는 각도에 따라 특징을 지니도록 표현한 경우에도 창작성이 인정될 여지가 있다는 내용이 기재되어야 합니다.

## 5. 사안의 경우 (2점)

특히, 제26조 제1항 및 제5항의 등록요건 판단 순서를 언급하시면서 차례대로 판단한 결과 모든 등록요건을 만족한다는 취지로 기재하시면 될 것 같습니다.

## III. 사안의 해결 (2점)

(1) 甲은 X출원은 공지된 건조물인 석탑A의 모양과 유사하나, 석탑에서 납골보관함으로의 전용이 당업계의 상식으로 이루어지기는 어려워 창작성이 인정된다고 판단되므로 결국 X출원은 모든 등록요건을 만족하여 출원절차 상에서 요구되는 서류 등의 방식위반이 없음을 전제로 등록 가능할 것이다(다만, 추가적으로 말씀드릴 사항은 사안의 창작성 만족여부에 대해서는 반드시 명확한 답이 있지는 않다는 것입니다. 실제로 납골당은 절에 많이 위치해 있으며 따라서 납골보관함과 석탑의 전용이 당업계의 상식으로 이루어질 수 있다고도 판단될 수 있기 때문입니다. 따라서, 창작성에 대한 단문 및 사안을 잘 적용하여 내용을 구체적으로 기재하시는 것이 보다 중요하다고 판단됩니다.).

(2) 최근 논의된 개정안에는 국내 출원디자인의 창작성을 높이하고자 국외에서 널리 알려진 형태도 용이창작의 적용대상으로 하고자 하였으며 최근 공포된 2014년 7월 1일 시행 예정 공포 개정안에서는 이를 반영하였다.

## 금년 디자인보호법 기출문제에 대한 총평

먼저 한 해 동안 정말 수고하셨다는 말씀을 드립니다.

올해 B-1문 이외에는 그렇게 크게 예상을 벗어나지는 않은 것 같아 그나마 마음의 위안이 됩니다. 또한, 작년 기출문제와 비교하여 판례사안에 대한 문제 및 중복논점에 대한 문제는 출제되지 않아 이 또한 큰 행운으로 작용할 것으로 짐작됩니다. 또한, B-1문의 경우에도 법조문 및 민사소송법을 포함한 관련내용을 언급하셨다면 충분히 배점을 받으실 수 있다고 생각합니다.

따라서, 저 개인적으로는 올해 디자인보호법 합격자의 비율이 작년보다는 배 이상으로 늘어날 것으로 자신하고 있습니다.

여러분들도 지금부터는 시험은 잠시 잊으시고, 그 동안 하지 못했던 일들을 하시면서 편하게 발표를 기다리시는 것이 좋을 것 같습니다.

다시 한 번 그동안 너무 수고 많으셨습니다. 감사합니다.

2013년 7월 31일

서상덕 배상